

1502031-33.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011). "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502031-33.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502031-33.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353797/2021 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS PATRICK CLEMENTE DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1502031-33

VISTOS.

JONAS PATRICK CLEMENTE DA SILVA e MOISÉS SOUSA RIBEIRO, qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios delituosos entre si e com o adolescente E.G.A. foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de dezembro de 2021, por volta de 09h35, na Rua Vasco da Gama, n.º 12, Bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, guardavam e tinham em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 3,9g (três gramas e nove decigramas) (item 1), e 39 (trinta e nove) invólucros plásticos, em forma de tabletes, contendo Cannabis Sativa L., "maconha",

com peso líquido de 996,5g (novecentos e noventa e seis gramas e cinco decigramas) (item 2), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, Jonas e Moisés – que desde a adolescência se envolvem com atividades ilícitas – e o adolescente E.G.A. se ajustaram para a prática do tráfico de drogas na residência situada no endereço acima mencionado, uma viela na qual reiteradamente são registradas ocorrências policiais e prisões em flagrantes relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Além de considerável quantidade de entorpecentes, mantinham no local vasto material para fracionamento e embalagem das substâncias.

Ocorre que, em plena prática delitiva, Jonas foi surpreendido por guardas municipais no momento que saía da residência manuseando um machete nas mãos. Revistado, em sua posse foi localizada 01 (uma) porção de maconha – dentro do objeto triturador – e a quantia de R\$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Ato contínuo, como a porta da casa estava aberta, os agentes visualizaram outras porções de droga num balcão e iniciaram as buscas no imóvel, onde abordaram Moisés e o adolescente E.G.A. que repousavam em um sofá ao lado do balcão.

Além dos entorpecentes que estavam no balcão – 02 (dois) tabletes de maconha e 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack – os agentes localizaram faca, rolos de plástico filme e fita isolante, comumente utilizados no fracionamento e embalagem de porções das substâncias.

Com auxílio de cão farejador, encontraram no quintal do imóvel uma sacola enterrada contendo outras 37 (trinta e sete) porções de maconha idênticas àsquelas encontradas no balcão próximo (foto fls. 18/19).

Outros materiais – para se apurar a devida origem – foram apreendidos na casa, tais como 01 (um) televisor e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Na delegacia, os réus Jonas e Moisés negaram envolvimento com a droga (fls. 06/07), enquanto o adolescente E.G.A. assumiu a propriedade de todo o ilícito dizendo que o teria adquirido na cidade de Santa Bárbara/SP (fls. 08).

Em exame pericial, constatou-se a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto de exibição e apreensão fls. 15/17 e laudo pericial fls. 21/25).

Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente a utilização da residência situada em área do tráfico, a apreensão de elevada quantidade de droga acompanhada de utensílios e materiais comumente empregados no fracionamento e embalagem, dinheiro em espécie e a condição pessoal, é certo que Jonas e Moisés, envolvendo o adolescente E.G.A. guardava e tinham em depósito as drogas com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fl. 106), sendo determinada a notificação dos réus para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 110/111). Os réus Moisés e Jonas foram notificados (fl. 118 e 120) e apresentaram defesa prévia, na qual requereram a revogação da prisão preventiva e alegaram inocência (fls. 124/127).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 136/139). Os réus foram citados (fls. 189 e 190).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns e 01 testemunha de defesa, sendo os réus interrogados (fls. 194/195).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 206/232).

A Defensoria Pública, em defesa do réu Moisés, alegou, preliminarmente, ilicitude probatória diante da inconstitucional e ilegal atuação da Guarda Municipal, bem como ilicitude do ingresso dos guardas no imóvel. No mérito, pleiteou a absolvição de Moisés, por falta de provas. Subsidiariamente, na dosimetria da pena, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade e confissão, caso a pena seja aumentada na primeira fase; aplicação do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas; fixação do regime prisional diverso do fechado ou aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E por fim, o direito de apelar da sentença em liberdade (fls. 236/250).

A Defensora do réu Jonas, por sua vez, alegou nulidade processual, diante da

violação de domicílio efetuada pelos Guardas Municipais. No mérito, alega inexistência de provas quanto ao crime de associação para o tráfico. Requer a improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, pede que seja fixada pena no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, fixação do regime aberto e possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 251/258).

É o relatório.

DECIDO.

I - Das Preliminares

1) Pleiteia a Defesa do réu Moisés, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante dos réus.

O réu Jonas foi avistado pelos guardas municipais, manuseando um dichavador como se estivesse dichavando maconha, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que motivou sua abordagem.

Durante a abordagem e ainda do lado de fora, os guardas visualizaram entorpecentes no balcão da cozinha da casa, da qual Jonas havia saído.

Diante deste contexto, não se verifica atos de diligência investigativa efetuada pelos guardas municipais e nem tão pouco qualquer abuso ou ilegalidade, na medida em que abordaram o réu Jonas saindo de uma residência, em local conhecido como ponto de venda de drogas, trazendo nas mãos um dichavador, que ia movimentando e, por isso, havia a certeza de que havia entorpecente em seu poder, como de fato se mostrou.

Além disso, como a porta da casa de onde Jonas saiu tinha sido deixada por ele aberta, do lado de fora, os guardas civis já conseguiram visualizar o entorpecente que estava em cima do balcão de madeira, havendo certeza da prática delitiva (fotografia de fls. 19).

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, Jonas foi abordado na posse da maconha que preparava e Moisés e o adolescente foram abordados dentro da casa, dormindo, depois que os guardas já tinham avistado a droga do lado de fora da residência (fotografia de fls. 19), havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144,

§ 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - Resp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuararam sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de

COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCR: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis - Réus em situação de flagrância, cuja prisão

pode ser efetuada por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base fixadas em seus patamares mínimos - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

2) A Defesa de ambos os réus também alegou que a prova é nula, na medida em que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial.

Em recurso extraordinário representativo da controvérsia assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior

ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de tráfico de drogas permanente, os agentes policiais tinham a possibilidade de ingresso na residência, desde que houvesse justa causa.

E a justa causa encontra abrigo nos autos.

Como se verifica da prova oral, os guardas civis visualizaram o réu Jonas saindo de uma casa e, quando observaram do lado de fora, já que a porta estava aberta, viram drogas sobre o balcão, conforme fotografia de fls. 19.

Havendo drogas no balcão, já havia a certeza do flagrante, portanto, o ingresso na residência foi lícito.

Ainda que assim não fosse, os guardas civis afirmaram que Jonas autorizou o ingresso na residência, porquanto o restante da droga estava enterrado, na certeza da impunidade.

E embora Jonas tenha mencionado que não houve autorização, seu interrogatório não pode ser tomado como preponderante.

Assim, quando os policiais ingressaram na residência, tinham a certeza da existência da droga no interior da casa e, portanto, havia justa causa à ação policial.

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, nas fotografias de fls. 18, no laudo de constatação de fls. 21/25, bem como nos exames químico-toxicológicos de fls. 144/145 e 147/148, segundo o qual foi detectada a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína no material apreendido e Tetrahydrocannabinol (THC) no dichavador.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída aos réus.

Na Delegacia de Polícia, o réu Jonas disse que conheceu umas meninas, as quais não sabe informar os nomes, e dormiu junto de Moisés e Ezequiel na residência delas. Na data dos fatos, pela manhã, Ezequiel saiu daquela residência e, quando acordou, ele estava com os guardas municipais no interior da residência na qual dormiam. Os guardas encontraram maconha no armário que tinha na residência, mas a droga não lhe pertencia. Não sabia de sua existência no local. Foi algemado e conduzido até a Unidade Policial (fl. 06).

Em juízo, o réu Jonas afirmou que no dia 29/12/21, estava na casa de Ezequiel. Estariam fazendo algumas festas em Piracicaba. No dia 29, estava sentado na frente da casa, passou uma viatura, os guardas fizeram a volta e voltaram andando. Ficou sentado no mesmo lugar e foi abordado. Os guardas queriam saber onde morava. Disse que era em São Pedro, mas que estava naquela casa. Os guardas pediram autorização para entrarem na casa, mas disse que não poderia. Eles entraram e Moisés e Ezequiel estavam na casa. Ezequiel falou que não tinha nada na casa e, por isso, falou que não tinha nada. Os guardas levaram o cão de faro, que saiu pela janela. Os guardas disseram que havia marcas de sujeira na parede e a terra estava revirada, de forma que encontraram as drogas ali. Em razão disso, foram levados à Delegacia. Foi abordado do lado de fora da casa, tomando sol. Estava com o dichavador na mão. A porta da casa estava encostada e não aberta. Não havia drogas no balcão. A droga não era dele. Quando os policiais perguntaram de quem era a droga, ninguém falou nada. Só na Delegacia é que Ezequiel falou que a droga era dele. A casa era dele e

ele que sabia de quem era a droga. Não sabe se Ezequiel vendia drogas, mas ele ficava numa esquina, perto da casa, com outros moleques. Faz uso de maconha e consegue ficar sem consumi-la. Estava na casa desde 21/12. Tinha dormido ali, naquela noite. Na Delegacia, falaram que tinham ido por causa de uma festa. Não se lembra de ter dormido na casa de umas meninas. Conheceu Ezequiel pelo Facebook, porque ele é amigo de Moisés, há um mês e meio. Moisés é seu conhecido, desde pequeno, porque moravam na mesma rua. Não disse que a droga era sua. Não havia droga dentro da casa. Só tinha 02 tabletes pequenos de maconha, que havia levado de São Pedro. Essa droga tinha sido colocada dentro do dichavador. Só viu o crack na Delegacia. Não estava com dinheiro. Tinha R\$ 55,00 no bolso, que era para pagar sua passagem de volta. Moisés tinha R\$ 100,00, que tinha levado com ele. Falou aos guardas que a casa não era dele, de forma que não poderia autorizar (fls. 194/195). Inquisitivamente, o réu Moisés informou que estava dormindo com seus amigos em uma residência de conhecidas, que não soube declinar as qualificações, e, quando acordou, avistou os guardas no interior da residência. Depois de encontrarem entorpecentes, os quais estavam armazenados em um armário, foi conduzido sem uso de algemas até a Unidade Policial (fl. 07).

Em solo judicial, o réu Moisés falou que estava dormindo com Jonas e acordaram com o "tropic". Foi Ezequiel quem entrou na casa. Os guardas mandaram que levantassem e eles acharam R\$ 10,00 com ele e dinheiro com Jonas. Eles começaram a procurar na casa e o adolescente já assumiu tudo. Os guardas encontraram uma sacola de maconha e Ezequiel já assumiu tudo, na Delegacia. Só viu o crack na Delegacia, não tinha crack na casa. Não sabia que havia droga na casa. Conheceram Ezequiel pelo Facebook e ele os convidou para uma festa. Vieram para Piracicaba e foram ao local. A festa era da prima do adolescente. A festa foi nessa casa. Ingeriram bebida alcoólica e, por isso, estava dormindo. Estava na casa há 02 dias, junto com Jonas. Não havia maconha em cima do balcão, estava tudo enterrado. Não sabe quem enterrou a maconha. Não estava vendendo ou fracionando drogas. Não usa drogas. A droga era toda do adolescente. Não sabia que ele vendia drogas, só soube na Delegacia. A casa era alugada por Ezequiel. Tinha dormido naquela casa, naquela noite. Curtiram e acabaram dormindo na casa de Ezequiel. Falou que dormiu na casa de Ezequiel e não na casa das meninas. No armário não tinha droga (fls. 194/195).

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída aos réus. Vejamos.

O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Júnior relatou que estava em diligência em uma viela, onde ocorre tráfico de drogas, a pé. Avistaram o réu Jonas saindo da residência, que ficava nessa viela, com um dichavador na mão e o manuseando. Ele foi abordado e, de fato, havia maconha no dichavador, que estava sendo dichavada. Com ele ainda havia R\$ 155,00 em dinheiro. Jonas tinha saído de uma casa e tinha deixado a porta aberta, antes de ser abordado. Pela porta, do lado externo, conseguiram visualizar um balcão, onde havia mais drogas. A droga estava bem exposta. Num sofá, havia mais dois elementos dormindo. Na revista, nada de ilícito foi encontrado com eles. Jonas falou que nada mais de ilícito haveria no local. Solicitaram o canil e o cão de faro encontrou, numa área, pertencente ao imóvel, uma sacola plástica, com 37 tabletes de maconha, embalados da mesma forma daqueles 02 que estavam sob o balcão. Essa área era o quintal dessa casa. Em cima da pia, havia uma bolsa, com faca, fita isolante e filme plástico. Jonas falou que esse material era usado para o embalo da droga. Também havia uma TV e 04 celulares, um de Jonas e outro do adolescente. Como ninguém sabia explicar a procedência, todo o material foi levado à Delegacia. Moisés afirmou que era adolescente, mas posteriormente apuraram que ele era maior. Jonas assumiu a propriedade de toda a droga. Moisés e o adolescente falaram que moravam na residência há pouco tempo e que não tinham conhecimento das drogas. Ficou bem claro que eles também tinham conhecimento das drogas. Não conhecia nenhum dos réus. A droga estava no balcão e os instrumentos estavam numa bolsa numa pia ao lado. Jonas estava com o dichavador e o reconheceu como o réu mais moreno. A frente da casa já dá acesso à viela. Ele foi abordado e de imediato já viram o interior da casa. Jonas autorizou o ingresso na casa. Ele estava bem confiante de que não encontrariam o restante da droga, porque estavam enterradas (fls. 194/195).

No mesmo sentido, o também guarda municipal Felipe Vieira Alves alegou que estavam

em patrulhamento e existe um local que dá acesso a uma viela e é bem conhecido pelo tráfico. Por isso, fizeram incursão a pé e visualizaram o réu Jonas saindo de uma casa da viela com um dichavador na mão, fazendo movimentos. Ele foi abordado e, de fato, havia maconha dentro do dichavador. Com ele também havia R\$ 155,00 em notas miúdas. Perguntaram ao Jonas onde ele morava e ele disse que era na casa de onde tinha saído. Visualizaram do lado de fora da casa, porque a porta estava aberta, um balcão com porções de maconha e crack. Jonas confirmou que estava realizando o tráfico de drogas no local. Jonas falou que não tinha mais drogas na casa e autorizou o ingresso na casa. Acionaram o Canil e, ao ingressar na casa, encontraram Moisés e o adolescente. O cão de faro encontrou enterrado no quintal dessa casa 37 porções de maconha iguais àquelas que estavam no balcão da casa. O quintal era pequeno, de terra e murado. Jonas assumiu a propriedade de toda a droga. Moisés e Ezequiel falaram que moravam há pouco tempo na casa e não tinha conhecimento das drogas, negando o tráfico de drogas, embora a droga estivesse bem exposta. Apreenderam TV e celulares, cuja procedência não foi confirmada. Moisés alegou ser menor, mas, na Delegacia, apurou-se que era maior. Não conhecia os réus e o adolescente. Mesmo já tendo visualizado a droga, o réu Jonas disse que não havia mais drogas e autorizou a entrada na casa. Foi Jonas e não Ezequiel quem assumiu a propriedade da droga. Não acompanhou o interrogatório dos réus na Delegacia (fls. 194/195).

Perante a autoridade policial, o menor E.G.A. afirmou que a droga encontrada é toda sua, não pertencendo aos réus. Comprou em Santa Bárbara, no entanto, não sabe dizer o endereço nem nome da pessoa que lhe vendeu (fls. 08).

Judicialmente, o adolescente E.G.A. contou que ele estava dormindo com Moisés e Jonas estava acordado. O policial chegou e entrou na casa. "O cara falou que ia fuder com a vida do Jonas". O policial falou se tinha droga e disse que não, embora houvesse. O policial achou a droga que estava num beco, ao lado da casa. Essa droga era sua. Não havia droga em cima do balcão. Os policiais também apreenderam TV, uma faca, uma mochila, coisas que "não tinham nada a ver". Eles também acharam uns kits de "rocha" "que não eram nem nossa". Indagado "De quem?", respondeu "só minha". A casa tinha sido por ele alugada de Gustavo. Estava morando ali há 06 ou 07 dias. Morava com uma menina e, quando a menina foi embora, os moleques foram passar uns dias com ele. A droga estava enterrada, mas não foi necessário o uso do cão de faro. Pulando a janela da casa, dava acesso a um beco, onde a droga estava embalada. Não responde a processo em razão desse fato. Jonas e Moisés não vendiam drogas com ele. Só ele vendia drogas. Jonas e Moisés só iriam passar o final do ano com ele. Os policiais estavam com cão de faro, mas não precisava. Não ouviu Jonas confessar que a droga era dele. Na Delegacia, falou que a droga era sua, para os guardas nada falou. Conhece Jonas e Moisés há pouco tempo, uns dois meses. Mesmo assim, eles já ficavam na sua casa. Eles só dormiam e ficavam com umas "minas" na casa, enquanto vendia drogas. Tinha um quilo de maconha guardado, já picado e guardado. Só havia droga enterrada. Não havia droga no balcão. Jonas estava com um dichavador. O papel filme era usado para embalar a droga. Quando os guardas chegaram, Jonas estava de pé, Moisés estava deitado e ele também estava deitado. Jonas e Moisés não sabia das drogas. Jonas estava com o dichavador na mão. Não sabe de onde apareceu o crack. Só o viu na Delegacia. A maconha era deles (fls. 194/195).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento dos réus com a droga apreendida.

O réu Jonas e Moisés, em solo policial, negaram ter envolvimento com a droga apreendida, afirmando que desconheciam a existência da droga na residência. Em audiência, os réus negaram qualquer envolvimento com a droga, dizendo que só estavam na casa de Ezequiel para passar as festas de comemoração do final de ano, sem terem conhecimento da existência da droga. Jonas alegou que ele foi a pessoa que foi abordada, do lado de fora da residência, enquanto estava sentado. Já Moisés alegou que quem foi abordado foi Ezequiel, porque ele e Jonas estavam dormindo. Ao lado da versão dos réus, existe o depoimento do adolescente, segundo o qual, perante a autoridade policial disse que adquiriu a droga em Santa Bárbara D'Oeste, negando envolvimento dos amigos com o entorpecente. Em Juízo, ele afirmou que havia

alugado a casa e os réus estavam ali para passarem as festas de final de ano, no entanto, eles não tinham conhecimento da existência da droga. Aduziu que ninguém estava do lado de fora da casa, quando abordados pelos guardas civis e que não havia nenhuma droga em cima do balcão, dentro da casa, apenas enterrada. Assumiu a propriedade de toda a droga e alegou que a estava vendendo.

Contrariamente à prova acima mencionada, há a palavra dos guardas municipais, que narraram que adentraram a pé em uma viela, local conhecido pela prática de tráfico de drogas e visualizaram o réu Jonas saindo de uma casa mexendo num dichavador que levava nas mãos. Ele foi prontamente abordado, já que o instrumento é usado para preparar a maconha. Com ele, foi encontrado o dichavador com a maconha já preparada, além de R\$ 155,00 em cédulas miúdas. Quando saiu da casa, Jonas deixou a porta aberta e, por ela, ainda do lado externo, os guardas civis puderam observar, sobre um balcão de madeira, dois tabletes de maconha e pedras de crack. Os guardas civis ingressaram na casa e conferiram a existência de 55 porções de crack. Nessa residência, no sofá, ainda estavam dormindo o adolescente E. e Moisés, com os quais nada foi encontrado. Aos guardas civis, Jonas confessou que toda a droga era dele e que estava traficando. Com o apoio do cão de faro, conseguiram encontrar, enterrada no quintal da casa, uma sacola, contendo mais 35 tabletes de maconha. Dentro da residência, sobre a pia, ainda havia uma bolsa, na qual havia 01 faca, 02 rolos de plástico filme e 01 rolo de fita isolante. Jonas assumiu a propriedade de toda a droga, mas E. e Moisés afirmaram que não tinha envolvimento com o crime. Com efeito, resta saber se ambos os réus tinham ou não envolvimento com a droga apreendida.

Inicialmente foi Jonas quem assumiu a propriedade da droga aos guardas civis. De outro lado, as drogas estavam sobre um balcão, a mostra, de forma que ninguém poderia não as tê-la visto.

Nesse contexto, entendo que impossível se considerar que o adolescente fosse o único responsável pela droga, em razão de sua quantidade e da necessidade de aporte financeiro para adquiri-la.

Ademais, a residência fica em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde a dinâmica se faz com vistas a essa atividade criminosa.

Não há, por outro lado, qualquer justificativa para que os réus estivessem no local sem envolvimento com o entorpecente. Aliás, Jonas foi abordado enquanto preparava maconha para ser consumida, ou seja, teve livre acesso à droga.

Por outro lado, a versão dos réus e do adolescente não merece credibilidade. De início, aos guardas civis, apenas Jonas assumiu a propriedade da droga, ficando o adolescente em silêncio, só vindo a se manifestar na Delegacia de Polícia, fato curioso para quem quer assumir a responsabilidade delitiva.

De outro lado, ambos os policiais disseram que Jonas foi abordado do lado de fora da casa, fato confirmado pelo próprio réu Jonas. Moisés, contudo, alegou que era Ezequiel quem estava do lado de fora da casa e Ezequiel mencionou que foi o guarda civil quem ingressou na casa.

Também a motivação para que os réus estivessem na residência não tem unicidade.

Cada réu disse um tempo em que estavam na casa ou a motivação para tanto, diferentemente daquilo que o adolescente mencionou.

As discrepâncias nas versões dos réus e do adolescente levam à certeza de que os guardas civis forneceram a versão verdadeira, na medida em que os depoimentos são seguros e unânimes.

A prova, portanto, indica que os réus também tinham relação com a droga apreendida na residência em que estavam.

Importante mencionar que a palavra dos guardas civis, como funcionários públicos que são tem relevância e merece credibilidade, na medida em que não estão impedidos de depor. Por outro lado, observa-se que estão em consonância com o conjunto probatório:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro

JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Ressalto que os guardas municipais não conheciam os réus e se quisessem prejudicá-los poderiam ter feito com menor quantidade de drogas.

Comprovado o envolvimento dos réus com a droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos

punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, os réus alegaram que as drogas não lhes pertenciam, nada mencionando sobre sua destinação. A prova, contudo, confirma a destinação e consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, Jonas foi abordado em viela onde o tráfico de drogas é intenso. Dentro da residência, havia entorpecente no balcão, cuja quantidade e forma de emalo revelam a destinação de consumo de terceiras pessoas (02 tabletes de maconha e 55 pedras de crack).

Sobre a pia, havia 01 faca, 02 rolos de plástico filme e 01 rolo de fita isolante, material usado para o emalo da droga.

Enterrado no quintal havia mais 37 tabletes de maconha, que foram encontrados pelo cão farejador.

A droga apreendida foi encontrada em grandes quantidades, juntamente com utensílios para a realização de embalagens para serem usados na traficância.

Informalmente, aos guardas civis, Jonas confessou que a droga era para a mercancia ilícita. E, em audiência, Ezequiel afirmou que a maconha era sua, destinada ao comércio ilícito.

Assim, o local da apreensão, a quantidade da droga, a forma de embalagem do entorpecente e os petrechos encontrados; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu Jonas seja usuário de entorpecentes, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

3) Da causa de aumento da pena

A pena dos réus deve